



行政法

「適正手続」

東京大学教授
北島周作
KITAJIMA Shusaku



行政活動と適正手続

1. 憲法と適正手続

憲法 31 条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」と規定している。この規定について、著名な憲法の教科書は¹⁾、手続が法律で定められることを要求するにとどまらず、①法律で定められた手続が適正でなければならないこと、②実体もまた法律で定められなければならないこと、③法律で定められた実体的規定も適正でなければならないことを意味するとしている。注意してもらいたいのは①と③の区別である。③は、ある行為に対して刑罰を科すためには法律が必要であるところ(②)、その内容が適正でなくてはならないことを示している。これに対して①は、そうした刑罰を科すためには、法律が定める適正な内容の手続によらなければならないとするものである。前者の適正性を実体的適正性というのに対して、後者の適正性を手続的適正性などという。適正な手続の具体的な内容は、憲法 33 条から 39 条でも定められている(例えば、33 条は令状主義を定めている)が、31 条が

保障している適正な手続の内容として、告知・聴聞の手続があるとされている。告知とは、相手方に事前にこれから行うことの内容を伝えることであり、聴聞とは、告知を受けた相手方の言い分を聞き取り、弁解と防御の機会を与えることである。

以上は、刑事手続に関する話であるが、行政活動をする際にも適正な手続が必要であると一般に考えられている。確かに、憲法 31 条は刑事手続に関する規定であり、憲法には行政手続に関する明文の規定はない。しかし、最大判平成 4・7・1 民集 46 巻 5 号 437 頁は、「憲法 31 条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」として、憲法 31 条の保障が及ぶ余地があることを認めている。また、学説においても、その根拠をなにに求めるかについては見解が分かれている(憲 13 条、手続的法治国原理など)²⁾、適正な手続が必要であること自体に反対する見解は見られないところである。

もっとも、より具体的に、いかなる場合に、いかなる手続が必要であるかということになると、話は難しくなる。ある憲法学者は、憲法 31 条の要求が「行政手続」にも適用されるべきといわれながら、その適用されるべき「行政手続」というのが具体的にいかなる手続を指すのか明らかではなかったと指摘している³⁾。また、先ほどの最高裁判決は次のように述べている。「同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である」。このように、告知・聴聞手続という手続をとっても、行政活動の多様性から、いかな

1) 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法〔第 7 版〕』(岩波書店, 2019 年) 252 頁以下参照。

2) 塩野宏『行政法 I 〔第 6 版〕』(有斐閣, 2015 年)

298 頁以下参照。

3) 松井茂記「行政手続におけるデュー・プロセス」ジュリ 1089 号(1996 年) 276 頁。

る場合にも要求されるものではなく、個別具体的に判断されることを要するものと考えられる。そのため、ある行政活動に対して特定の行政手続の履行を安定的に求めるためには、具体的な立法等の措置が必要であったといえよう。

2. 行政手続の法制化

ここで、具体的な法的根拠に目を向けてみよう。日本において、行政手続に関する一般法である行政手続法が制定されたのは1993年である。諸外国に目を向けると⁴⁾、1925年のオーストリアにおける行政手続諸法と呼ばれる一般行政手続法等からなる法律群が世界で初めての行政手続法とされている。日本でよく比較法の対象国として参照される国々では、アメリカでは1946年に、旧西ドイツでは1976年に連邦レベルの行政手続法が制定されている。フランスでは統一的な行政手続法は制定されていないが、1979年の理由附記法等により手続が整備されている。これらの国々と比べると、日本の行政手続法制定はかなり遅れたといえる。

行政手続法の制定までは、行政手続に関する一般法は存在せず、行政手続の履行は、もっぱら個別法に定められた手続規定に依拠していた。この時期、個別法において定められた手続規定の柔軟な解釈を通じて、条文で明示されていない内容を適正な手続として求める裁判例が登場し、注目を集めたが⁵⁾、個別法に手続規定が置かれていないことが多く、また、憲法等から直接、一定の手続を履行する義務を導き出すことが難しい状況のもとで、一般法の制定が長く待ち望まれていたところであった。

もっとも、1993年まで行政手続法制定の動きが全くなかったわけではなく、複数回の試みがなされていた。具体的にいうと、1952年に国会に提出された国家行政運営法案、1953年

に行政審議会運営部会が取りまとめた国家行政運営法案要綱（試案）には、行政手続に関する規定が含まれていた。1964年には、第一次臨時行政調査会が、「行政の公正確保のための手続の改革に関する意見」を出し、「行政手続法草案」を示している。1983年には、当時の行政管理庁において一般的行政手続法の整備について検討をしていた第一次行政手続法研究会が、「行政手続法研究会報告」を「法律案要綱」という形でまとめている⁶⁾。これらの試みが最終的な法律とならなかった理由としては、国民、事業者（経済界）、マスコミともに関心がなく、研究者以外に立法を推進する勢力が存在しなかったことが指摘されている。しかし、当時の総務庁の行政管理局に置かれた第二次行政手続法研究会の中間報告の後は、1991年の第三次臨時行政改革推進審議会の公正・透明な行政手続部会の設置と検討、その成果である「行政手続法要綱案」を含む「公正・透明な行政手続法制の整備に関する答申」、その内容を元にした行政手続法案の国会提出、行政手続法の成立へと順調に進むことになった。これは、当時、事業者を中心に、許認可等の審査基準の不透明性や、行政指導の恣意性等が問題視され、審査基準の明確化や行政指導のルール化に強い関心が寄せられていたところ、総務庁行政管理局の働きかけもあり、行政手続法の内容がこうした問題に対して有効であると認識され、マスコミが関心を寄せるとともに、事業者の支持を受けることができたためであるとされている⁷⁾。こうして制定された行政手続法は、伝統的な行政手続である告知・聴聞手続等も当然有するが、目的規定に、行政運営における公正の確保と透明性の向上が掲げられていたり、許認可等の申請に対する処分や行政指導について充実した規定を有するなど、立法の背景を反映した内容となっている⁸⁾。

手続法の立案に関与しているが、不公正・不透明な行政活動と戦った事業者の一人として知られる。ヤマト運輸は、一般路線貨物自動車運送事業免許を運輸大臣（当時）に申請したが、地元業者の反対を受け、その申請は長期にわたり棚ざらしにされたため、行政事件訴訟法に基づく不作為の違法確認訴訟を提起している（日経流通新聞1986年9月8日8頁）。その後免許が出されたため、この訴訟は取り下げられたが（日本経済新聞朝刊1987年2月16日朝刊9頁）、小倉氏は、自叙伝において、運輸省は法令上は免許を拒否できないため、棚ざらしにして事業者を取下げに追い込んでいた旨指摘している（小倉昌男『経営はロマンだ！』〔日本経済新聞出版、2003年〕136頁以下）。不公正な行政活動を防止するための行政手続が必要とされていたことを示す例といえる。

4) 諸外国における行政手続法の制定状況を簡潔に説明するものとして、宇賀克也『行政手続三法の解説〔第3次改訂版〕』（学陽書房、2022年）29頁以下参照。

5) 例えば、いわゆる個人タクシー事件（最判昭和46・10・28民集25巻7号1037頁）が有名である。

6) これらの立案の試みの内容を簡潔にまとめたものとして、宇賀・前掲注4)32頁以下を参照されたい。

7) 以上の第二次行政手続法研究会からの経緯については、増島俊之「行政手続法立案実務担当者の制度立法化をめぐる判断」同『行政改革の視点と展開』（ぎょうせい、2003年〔初出1994年〕）141頁以下に詳しい。

8) 「宅急便」の生みの親として有名なヤマト運輸の小倉昌男氏は、公正・透明な行政手続部会の委員として行政



行政手続の内容と機能

1. 行政手続の内容

——適正手続4原則

次に具体的に行政手続の内容を見ていきたい。行政活動をする際の手続は、行政活動の行為形式（行政立法、行政指導、行政行為など）、その効果（人民に対して利益を与えるものか、不利益を与えるものかなど）ごとに、様々なものがある。行政手続法は様々な手続を定めているが、それは一部でしかなく、個別の行政関係法律で定められている手続もある。また、外国における行政手続法に相当する法律が定める手続の内容も様々である。そうした中、国際的に見て、かなり共通して用いられていると見られる4つの手続があることが指摘されている（「適正手続4原則」などと呼ばれる）⁹⁾。その4つとは、Iで紹介した告知・聴聞のほか、文書閲覧、理由附記、処分基準の設定・公表である。これらの手続は、行政手続法においても、一定の行為をする際に要求されているところである。この4つの手続は行政手続の全てではないが、中核的なものといえる。そこで、以下、1つの裁判例を素材に、行政手続法の定めるこれらの手続の具体的な内容、機能を紹介しよう。

2. 行政手続の内容

——具体的な事案に即して

まず、素材となる裁判例の事案を紹介する¹⁰⁾。パチンコ店を営業するためには風俗営業法上、都道府県公安委員会の風俗営業の許可が必要であるが（2条1項4号・3条1項）、その許可は、出入国管理法73条の2第1項の罪を犯して1

年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者は得られないことになっている（4条1項2号ル）。そして、許可を受けた者について、この欠格要件に該当する事実が判明した場合は、公安委員会は「その許可を取り消すことができる」とされている（8条2号）。本件は、許可を得てパチンコ店を営業していた法人Aが、不法残留外国人を従業員として働かせていたとして、出入国管理法違反で起訴され、裁判で罰金刑が確定した後、県の公安委員会が営業の許可を取り消したものである。

この事案において、公安委員会が、Aの営業の許可を取り消す際に、行政手続法上いかなる手続をとらなければならないかを見てみよう。本件の営業許可の取消しは、行政手続法上、「不利益処分」というものに該当し¹¹⁾、関係する手続が定められている。

まず、罰金刑に処せられたことが判明した場合に許可の取消しができること自体は、風俗営業法が定めているが、それを実際にするかどうか判断するための具体的基準は明らかではない。この点、行政手続法は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を「処分基準」と定義し（2条8号ハ）、不利益処分の性質に照らしてできるだけ具体的に定め、公にしておくよう努めなければならないとしている（12条）。これは、前記「処分基準の設定・公表」を法制化したものである¹²⁾。なお、この事案は2004年のものだが、2005年改正後の行政手続法においては、「処分基準」は、「命令等」というものに該当し（2条8号）、それを定めるときには、原則とし

9) 塩野・前掲注2)295頁以下。I2で触れた第一次行政手続法研究会では、ヨーロッパ（当時の社会主義国を含む）を中心に多くの国々の法制について調査が行われ、また横断的に整理されている。この4原則を見出した塩野宏教授は、この第一次行政手続法研究会から公正・透明な行政手続部会まで一貫して関与された日本における行政手続法立案の中心人物であり、この4原則は、そうした調査、整理の中から見出されたものと推測される（なお、第一次行政手続法研究会の資料については小早川光郎教授所蔵のものを参照させていただいた）。

10) 盛岡地判平成18・2・24判自295号82頁。なお、本稿の脱稿直前に刊行された本誌2023年2月号に、この裁判例をモデルとし、事案に改変を加えて、さらにいくつかの適正手続に関する論点を付け加えた演習問題が掲載されていることを知った（鶴澤剛「演習」法教509号〔2023

年〕134頁）。この裁判例はそれほど有名なものではないため、この偶然に驚くばかりであるが、適正手続についての理解を深めるためにも、是非、この演習問題にチャレンジしてもらいたい。

11) 行政手続法2条4号は、不利益処分を「行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう」と定義しており、本件営業許可の取消しはこれに該当する。

12) ただし、適正手続原則としてあげられている理論上の「処分基準」はもっと広いものであり、行政手続法の「処分基準」だけでなく、「審査基準」（2条8号ロ）等も含む。他の原則についても、同じ又は類似の言葉が用いられていても理論上のものと行政手続法上のものの内容は必ずしも同じではないので、その内容の違いに注意する必要がある。

て、「意見公募手続」(命令等の案を公示し、それに対する意見を募った上で、提出された意見を十分考慮して定める手続)をとらなくてはならないとされている(39条・42条)。

次に、行政手続法によれば、許可を取り消す場合には、「聴聞」の手続をとらなくてはならない(13条1項1号イ)。これは、前記「告知・聴聞」手続を法制化したもので、具体的には、公安委員会は、Aに対して、予定される不利益処分の内容、原因となる事実等を通知し(15条)、指名する職員等に主宰者としてAの意見の聞き取りなどをさせて(19条・20条)、聴聞調書と報告書を作成させ(24条)、それらを十分に参酌して、許可の取消しをするか決定することになっている(26条)。なお、この聴聞の手続において、Aは、公安委員会が本件事案についてした調査の結果に係る調書その他の予定されている許可の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる(18条)。この「文書等の閲覧」の手続は、前記「文書閲覧」手続を法制化したものである。

そして、最後に、実際に許可の取消しをするときには、Aに対して、同時に、その理由を示さなくてはならない(14条1項)。「理由提示」手続と呼ばれるもので、前記「理由附記」手続を法制化したものである¹³⁾。

3. 各手続の機能

さて、行政手続法によれば、以上のような手続を行わなければならない。これはとても面倒なことであるが、求められる各手続はいかなる機能を有するのだろうか。

まず、「処分基準」であるが、先ほど述べたように、条文上、許可の取消しは義務ではなく、公安委員会は、許可を取り消さないこともできる。しかし、法律上、いかなる場合に許可を取り消さないのかは明らかではない。そのため、もし、案件ごとに、その都度、取り消すか取り消さないかを判断するとすれば、同様の事案で以前は取り消していたのに、今度は取り消さないといったことが生じ、法令の適用の公平性、一貫性の点で問題が生じる可能性がある。この点、取り消すか取り消さないかを判断するために依拠する処分基準を定めておき、それに

沿って判断するようにすれば、そうした問題が生じることをある程度防ぐことができるだろう。そして、その処分基準が公にされれば、Aは、聴聞で意見を述べる際等に、その内容に即した主張をすることができる。さらに、それがウェブサイト等でより一般的に公表されれば、広く公衆にその内容が知られることになり、その監視の目にさらされることになる。そのため、処分基準の内容が法令に照らして違法、不適切なものとならないよう、その内容を慎重に検討した上で定めることや、違法、不適切な場合は公衆の意見を受けて是正することも期待できる。また、前述のように、2005年改正以来、この処分基準は、原則として意見公募手続を経て定められるようになってきている。そのため、現在では、処分基準は、他の命令等と同じく、法定の手続により、慎重に制定され、また提出された公衆の意見の考慮が義務付けられることにより、内容に民意が反映される仕組みになっている。

次に、「聴聞」であるが、相手方であるAの言い分を聞くことにより、公安委員会が事実誤認により許可を取り消すことを防いだり、そこで得た新たな情報に基づいて許可の取消しを再考することが期待できる。なお、聴聞を実効的なものとするためには、公安委員会が依拠している資料をAが閲覧できるようにすることが有益である。なぜなら、どのような内容の資料に基づいて許可の取消しをしようとしているか分からないと有効な意見を述べるのが難しいからである。仮に資料の内容が間違っていたなら、それを指摘することができるのであり、「文書等の閲覧」の手続はこのように聴聞を実効的なものとする役割を果たす。

最後に「理由提示」である。この手続には、判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するという機能、理由を相手方に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという機能がある。すなわち、公安委員会は、許可の取消しを行う際に、聴聞を経て認定した事実を法令等に当てはめて、許可の取消しを決定する。ここで、理由を示さないといけなるとすると、いい加減な事実認定や法令等への当てはめをするわけにはいかず、慎重に判断せざるを得なくなる。また、そこで示された理由は、公安委員会の最終的な判断であるから、行政不服審査法や行政手

13) 理由附記は、文書で理由を示す場合を念頭において言葉であったが、行政手続法では、口頭により理由を示

す場合も含む趣旨で理由提示という言葉が用いられている。

件訴訟法に基づき争訟を提起して争うかどうか判断するための手掛かりともなる。

4. 本件事案における手続の履行内容

さて、本件事案では実際にどのようなことがなされたのだろうか。

この事案において、条文上は、許可の取消しをする場合、取消しをしない場合の判断基準が不明確であったところ、公安委員会は、処分基準を定め、処分の取消しを原則としつつ、欠格要件に該当するに至った場合でも、速やかに是正、回復等することができ、かつ、現に是正、回復しようとしている場合等で悪意がない又はごく軽微な場合をその例外としていた（法人の役員が欠格要件に該当するに至ったが、事実判明後、法人が速やかにその者の解任手続をすすめているようなときがその例として示されている）。この処分基準は、特定の場合を念頭においたもので、その射程は広くないが、それでも公安委員会による公平で一貫した許可の取消し、不取消の実現にある程度資するものであったと考えられる。そして、その内容は公にされていたので、（本件は例外に該当する事案ではなかったようであるが）仮にここで定められた例外に該当する場合であったならば、それを主張することも可能であっただろう。

次に、聴聞では、公安委員会は定められた手続に沿って聴聞を実施し、Aは、出入国管理法違反の事実関係は認めた上で、十分に反省していること、営業許可の取消しとなれば33人の従業員が路頭に迷うことになることなどを述べている。ここで、公安委員会は、Aに直接事実関係を確認しているが、それに加えてAの事情も聴取している。これらは処分基準には含まれない事情であるが、取消し、不取消の裁量判断をする上で、法令上、これらの事情を考慮することが否定されていないならば、公安委員会は、これらの事情を考慮して、許可を取り消さないこともできると考えられる。そうすると、聴聞は、事実関係を確認するだけでなく、そうしたAの事情を聴取する手続としても有

効に機能していたといえよう。

最後に、理由提示であるが、本件では、行政処分の区分が「営業許可の取消し」であること、取消しの日が「平成16年3月16日」であること、根拠となる法令の条項が「風俗営業法8条2号」であることが通知において示された。ここで、公安委員会は、形の上では理由提示手続を履行しているようにも見えるが、この内容で先ほどの理由提示に期待される機能を十分に果たしているといえるだろうか。風俗営業法8条2号は「第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること」というもので、4条1項各号を見てみると「ル」に「出入国管理及び難民認定法……第73条の2第1項の罪」とあるから、この内容から、A自身は、出入国管理法違反の有罪判決により許可が取り消されたということをおそらく知ることができるだろう。しかし、理由提示の機能に着目して形成された理由提示の程度に関する判例法理に照らすと、この内容では不十分と判断される可能性が高い。すなわち、判例法理では「いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して」当該処分がなされたのか、理由が示された書面の「記載自体から了知しうるものでなければならぬ」ことが要求されている¹⁴⁾。これは、書面に記載されていない情報は相手方が事実上知っていてもカウントしないというものである。なぜ、このようなことが要求されるかというと、判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するという理由提示の機能からすれば、公安委員会は事実関係と適用法規に誤りがないか慎重に確認しながら理由を記載していくことが求められるためである。本件において、裁判所は、この判例法理に従い、記載自体からは、風俗営業法4条各号のいずれに該当するか不明である上、不利益処分の原因となる事実の記載もないことを指摘している¹⁵⁾。また、本件では、聴聞において、Aから前記の事情が主張され、それを受けて作成された聴聞報告書では、理由として、当事者は事実を認めて寛大な処分を要求しているが、相手の事情等を考慮しても、これから許可を受けようとする者が欠格事項に該

14) 最判昭和60・1・22民集39巻1号1頁。なお、この判決は行政手続法制定前の旅券法に基づく理由提示に関するものであるが、行政手続法の不利益処分の際の理由提示に関する、最判平成23・6・7民集65巻4号2081頁においても継承されていると見られる。この平成23年判決を検討するものは多いが、さしあたり、北島周作「理由提

示の程度と処分基準」法教373号（2011年）49頁を参照されたい。

15) なお、前掲注14)最判平成23年が示す行政手続法のもとでの判例法理では、一定の場合に、法令だけでなく、処分基準の具体的適用関係も示さなくてはならないとしている。

当する場合には許可を得ることができないこととの均衡から取消しを免除することができないとされており、Aの事情を考慮した上で取消しの判断に至ったことが示されていた。そして、公安委員会は、訴訟の場でこれが判断の理由であったと主張している。これは処分基準に沿った判断でもなく、記載された理由からはこうした内容を到底読み取ることはできないが、聴聞と理由提示の機能を最大限発揮させるためには、こうした内容をAが知るができる形で理由を示すことが望ましいといえる。この点、裁判所は、聴聞で、汲むべき事情があることが主張され、それを考慮して裁量性判断（つまり、許可を取り消さない判断をするかどうか）をするかが唯一の争点となっており、処分の名あて人もその点の判断について強い関心を有しているにもかかわらず、通知にその点に関する記載がなかったことを理由提示が不十分である点として指摘している¹⁶⁾。このように、定められた手続は、単に形だけ履行すればよいというのではなく、その機能が発揮できる形で履行されることが求められていることに注意する必要がある。

5. 手続の瑕疵の効果

なお、行政手続法をはじめとする行政手続に関する法令の定め反して手続を全く履行しな

かった場合、あるいは、一応履行したが不十分であると判断された場合、法令違反であることは間違いないが、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の場でそう判断された場合に、それが、処分の取消事由となるかという問題がある。この問題は、行政手続の瑕疵の効果の問題などと呼ばれている。なぜ、問題となるかという、行政手続に関する違反の場合には、それを理由に裁判所が判決で処分を取り消し、行政庁に適法な手続で処分のやり直しをさせても、実体的には適法で、再度同じ処分がされるだけで結果が変わらない場合があるからである。そうした場合、行政手続が正しい結果を導き出すための手段であるとする場合、あえて処分をやり直させる意味はない。他方で、適法な手続を経てはじめて適法な処分となると考える場合、同じ結果となっても処分のやり直しをさせるべきだということになる。最高裁は、手続の瑕疵の結果への影響を考慮していると見られるが¹⁷⁾、手続の中でも理由提示については、結果への影響を考慮することなく取消事由としており、扱いが異なる¹⁸⁾。そのため、理由提示が不十分とされた本件でも、裁判所は、営業許可の取消しを判決で取り消している。学説でも活発に論じられているが¹⁹⁾、手続の本質にも関わる問題でもあるので、読者の皆さんにも是非考えていただきたい。

(きたじま・しゅうさく) ㊦

16) もっとも、後で触れるように理由提示の瑕疵が直ちに処分の取消しにつながることを考えると、求められる理由提示の程度としてどこまで要求するかは見解が分かれるところである。この点、前掲注14)最判平成23年の田原睦夫裁判官補足意見と那須弘平裁判官反対意見を比較してみるとよいだろう。

17) 前掲注5)最判昭和46年、最判昭和50・5・29民集29巻5号662頁。

18) 前掲注14)最判平成23年。

19) 関係する論文は多いが、多くの裁判例を分析する近時のものとして、大橋洋一『対話型行政法の開拓線』(有斐閣、2019年)226頁以下を紹介しておきたい。